

1500481-17.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500481-17.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500481-17.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marlon Candido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MARLON CANDIDO DA SILVA, qualificado à fl. 06, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 11h29min, na Rodovia SP 425, km 461, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente/SP, MARLON CANDIDO DA SILVA, qualificado à fl. 06, transportava, entre estados da federação, o entorpecente popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido aproximado de 1.893 kg (mil, oitocentos e noventa e três quilogramas), dividido em diversos tabletes, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 15/22 e 30/38) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (fls. 177/179). Segundo consta nos autos, o denunciado recebeu referida substância entorpecente no Estado do Paraná com o

compromisso de transportar o entorpecente até a cidade de São Paulo e, assim, fomentar o tráfico de drogas interestadual. A droga foi inserida no interior de móveis transportados pelo denunciado no caminhão de placas QRM-9I40, marca VW, cor branca, ano 2019, como forma de dificultar a fiscalização por agentes estatais. Ocorre que, policiais militares rodoviários realizavam fiscalização de rotina e ao avistarem o denunciado conduzindo o aludido caminhão notaram que ele apresentou nervosismo exacerbado, razão pela qual deram ordem de parada. Durante a abordagem, em vistoria ao semirreboque, foram localizados os diversos tabletes contendo "maconha" dentro dos móveis. A análise das circunstâncias e do local da apreensão, da grande quantidade e natureza da droga apreendida, permitem a conclusão que a droga era destinada ao tráfico interestadual. Além do entorpecente e do veículo, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de telefones celulares das marcas Xiaomi e Samsung, além da quantia em dinheiro de R\$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) sem comprovada origem lícita, conforme auto de apreensão de fls. 13/141.1 (Também fora apreendido uma carga de madeira (guarda-roupas desmontados), mas já entregue ao respectivo proprietário, conforme consta à fl. 181.)". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 223/227), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 230), o despacho de fls. 232/235, de 29 de julho de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 270/271), pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 270/271), em razão da confissão espontânea do réu em Juízo, detalhando a conduta criminosa, requer que a pena seja aplicada no mínimo legal, ausentes outras agravantes e causas de aumento, presente, contudo, na terceira fase, a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, tendo em vista que o réu não possui antecedentes, e não integra organização criminosa ou se dedique a qualquer atividade criminosa, e pela causa de aumento da interestadualidade do transporte de droga, que lhe seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; pelas fotografias de fls. 15/22; pelos documentos de fls. 23/38; laudo de constatação preliminar de fls. 40/42; pelo laudo químico toxicológico de fls. 177/179, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0036589) Descrição: 05

(cinco) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo. Massa Bruta e/ou Quantidade: 3,505 quilograma(s) - três quilogramas e quinhentos e cinco gramas. Massa Líquida: 3,42 quilograma(s) - três quilogramas e quarenta e dois decagramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial em aparelho celular de fls. 258/268; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha PM Rodoviário Rodrigo Brunhani, sob o crivo do contraditório, declarou que estavam em patrulhamento na rodovia quando o veículo do acusado passou e perceberam que ele estava manuseando seu celular e chamou a atenção da equipe. Abordaram o veículo numa fiscalização de trânsito normal e ele

desceu do veículo já nervoso, com voz diferente aparentando bastante nervosismo. Disseram que levariam o veículo para a base para fazer uma vistoria minuciosa, quando ele confessou que no caminhão havia uma carga de maconha. Afirma que ele disse que receberia a quantia de R\$ 25.000,00, e com ele havia uma quantia, mas não se lembra o valor. Quando ele desceu do caminhão com o celular na mão, pode perceber que ele estava sendo acompanhado por um batedor. Afirma que ele vinha do estado do Paraná e ia para a São Paulo. Afirma que não tentaram averiguar se havia mais alguém acompanhando o réu durante o trajeto.

A testemunha Edilson Souza Silva, declarou que é Policial Militar Rodoviário, e sob o crivo do contraditório declarou que estavam operando o radar na operação de controle de velocidade e assim que ele passou, ele começou a manusear o aparelho celular o que despertou interesse na sua abordagem apenas por fiscalização de trânsito para confeccionar multa de celular e demais ocorrências. Durante a abordagem ele aparentou nervosismo e indagado sobre o que carregava no compartimento de carga, a princípio disse que eram móveis, que vinha de Arapongas/PR com destino a São Paulo. Informamos que levaria o veículo para a base, e como era caminho dele, já estava nas proximidades da base para uma vistoria mais minuciosa, quando ele acabou por confessar que entre a carga de móveis teria um carregamento de drogas, aproximadamente 1800 kg de droga, maconha. Foi localizado um cheque-frete no valor aproximado de R\$ 1.200,00 e mais R\$ 600,00 em espécie. Afirma que o acusado não disse de quem pegou a droga, apenas disse que o conhece por Sardinha, mas não sabe seu nome e disse conversou apenas por telefone, que transportaria a droga de Cidade Gaúcha/PR para São Paulo e receberia R\$ 25.000,00 pelo transporte.

A testemunha Lúcia da Silva Mariano declarou que é esposa do réu e por isso presta depoimento apenas como informante. Sobre os fatos disse que não viu o que ocorreu, ficou sabendo quando ele lhe telefonou dizendo que estava preso, nem sabia, porque o Marlon nem é dessas coisas, ele saiu para trabalhar. Afirma que ele saiu para trabalhar, ir para Maringá para trabalhar, mas não disse o que, mas ele é caminhoneiro, estão muito apurado, devendo muito, então ele foi para...fazer uma viagem. É a primeira viagem com esse caminhão, ele é motorista de caminhão há 12 anos. Marlon tem problema de coração, na tireoide que tem que fazer uma cirurgia, diabetes, um monte de problema. Ele é um bom marido, não tem o que falar dele. Marlon não tem outros processos, é honesto e trabalhador.

Em seu interrogatório, Marlon Candido da Silva, declarou que nunca foi preso ou processado anteriormente. Sobre os fatos disse que são verdadeiros. Pegou o caminhão para fazer essa viagem, pois estava desempregado há 6 meses devido ao covid, com problemas de saúde, e pegou esse caminhão para fazer essa viagem, fez o frete normal, e lhe ofereceram para completar a carga na Cidade Gaúcha, onde foi abordado por um carro e disseram que era ali para carregar, achou estranho e perguntou onde carregaria, e disseram que era ali mesmo no meio da cana. Colocaram em cima, não sabe a quantidade, mas foi carregada a droga e lhe pagariam R\$ 25.000,00 para deixar em São Paulo e fez, não tinha como abortar a missão, pois estava no meio do canavial, então carregou e foi embora. Chegando em Prudente, após Pirapozinho foi pego. Durante o percurso não se comunicava com ninguém, somente se comunicaria quando chegasse em São Paulo. O celular apreendido era seu e o outro, não chegou a fazer nenhuma ligação nele. Quando pegou o caminhão já tinha outro celular dentro do caminhão. Afirma que não ficou nervoso pela abordagem dos policiais mas porque estava passando o horário do seu remédio e não tinha tomado ainda. Afirma que possui problemas de saúde, precisa fazer cateterismo pois tem 40% das veias entupidas e sete nódulos da tireoide que tem que fazer cirurgia com urgência, já era para ter feito, informando essa situação ao presídio. Disse que o número do telefone que deveria avisar quando chegasse em São Paulo estava dentro do caminhão e acredita que ainda esteja lá, no painel do caminhão. Também tinha R\$ 600,00 que sobrou do frete após o abastecimento e um cheque do frete da Arildo Transporte do frete de móveis.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento

dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

No caso vertente, confirmada pelas palavras dos policiais militares que realizaram a diligência, que por si só serviram suficiente para impor o reconhecimento da ocorrência dos fatos como narrados na denúncia e autoria deles pelo réu. Eles afirmaram que visualizaram o réu ao telefone enquanto dirigia o caminhão e resolveram abordá-lo rotineiramente como infração de trânsito e perceberam o nervosismo do réu, decidindo por levá-lo até a base para uma vistoria mais minuciosa quando disseram que o réu confessou que estava carregando a enorme carga de maconha.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

"Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. ((RJTJSP 125/563))".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))".

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção do agente.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas e eram transportadas, denota-se de pronto, sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância

apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.). "ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Insta anotar no que concerne à tipicidade da conduta, que o crime de tráfico de drogas, prescrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, trata-se de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo, e a conduta do réu fica evidente no verbo "transportar" drogas, o que de fato, fica configurado estreme de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas.

Fica igualmente demonstrado o dolo na conduta, que é elemento subjetivo do tipo, já que sabia o que iria transportar e aceitou o encargo criminoso, e para o qual receberia como forma de pagamento, R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Assim, suficientemente demonstrado nos autos que o réu, praticou o delito de tráfico de drogas entre estados da federação, quando saiu de Arapongas dirigindo até o município de Cidade Gaúcha, ambas no estado do Paraná, onde recebeu proposta de levar grande quantidade de drogas, com um veículo que nem é de sua propriedade, e se dirigiu para este Estado, que levaria até a cidade de São Paulo, quando foi abordado e preso na base da Polícia Militar Rodoviária nesta cidade, que encontraram a enorme quantidade de drogas e realizaram a prisão em flagrante deles, conforme demonstra as fotografias de fls. 15/22.

De rigor por esse conjunto probatório a condenação do réu pelo delito de tráfico qualificado em razão do transporte entre dois estados da Federação, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).
Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".
"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma

das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114). Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]" (Acórdão 1000569, 20130110716564

APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que as rés são primárias e não registram antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhes são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase ausentes circunstâncias agravantes, entretanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, contudo, deixo de aplicá-la pelas duas circunstâncias atenuantes, pois "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira e última fase, aumento em 1/6 (um sexto), em decorrência do tráfico ter se dado entre Estados da Federação, conforme art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Por fim, por se tratar de réu primário, embora seja uma razoável quantidade de droga apreendida, não se pode presumir dedicação ao fato criminoso aqui tratado como pertencente a organização criminosa e nem se dedique a qualquer atividade de cunho criminoso, de modo que estão presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/06, é o caso de aplicação do redutor de pena em questão. A fração a ser adotada será a intermediária - 1/2 -, já que a droga era apenas maconha, substância nociva e viciante, que causa severas consequência à saúde pública.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagar 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art.

5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital de Esperança (do Câncer) de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, as rés cumprirão a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu MARLON CANDIDO DA SILVA, RG: 3522767, nascido em 22/09/1963, natural de São João do Ivaí - PR, filho de Salvador Candido da Silva e Nancy Aporecida Defentti da Silva, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente; e a pagar a multa de valor correspondente a 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, caput, c/c o § 4º, e artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006.

INCONTINENTII, expeça-se alvará de soltura em favor do réu, ante a qualidade do regime prisional adotado neste momento, encaminhando ao presídio em que encontra-se recolhido para o devido cumprimento.

Quando da execução as multas deverão ser corrigidas monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Em razão de que o dinheiro (R\$ 627,00) e aparelhos celulares apreendidos, foram utilizados para a prática do grave crime de tráfico, decreto a sua perda em favor da União. Comunique-se.

Apenas para que não paire dúvidas, esse valor não foi comprovada a sua licitude nos autos, ao contrário do cheque-frete no valor de R\$ 1.220,00 (fls. 163/164), que ficou devidamente demonstrado a sua origem lícita.

Quanto ao veículo apreendido, a prova não se mostrou firme a demonstrar ter sido transformado para o transporte da droga, haja vista que o caminhão estava carregado com mercadorias lícitas e a droga escondida no meio dela, e que também há discussão acerca da sua restituição em sede de Mandado de Segurança que figura como impetrante J.C. Batista Transportes em trâmite no E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sem ainda uma decisão definitiva, embora tenha sido indeferida a liminar arguida.

Dessa forma, para a restituição de bens apreendidos, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (TRF da 1ª Região, Acr n. 1999.36.00.009480-0-MT, Rel. Des. Fed. Cândido Ribeiro, j. 22.02.05), e assim, a referida questão deverá ser dirimida na seara Cível, em procedimento próprio.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a

concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA